

محاضرة في المادة:

تعديل العقد

ماستر 1 – س1

2022-2021

من إعداد:

الأستاذة وعراب سليمة

تعديل العقد

المقدمة

يقوم العقد على مبدأ سلطان الإرادة ويعني ذلك أن للمتعاقدين الحرية المطلقة في تحديد محتوى العقد والالتزامات التعاقدية، بشرط أن لا تكون مخالفة للنظام العام والآداب العامة وحسب أنصار هذا المبدأ لا أحد يراعي التوازن العقدي أكثر من المتعاقد ذاته، بمعنى أن المتعاقد يكون أشد حرصاً على تحقيق مصلحته.

وبما أن العقد تصرف قانوني يتمتع بالقوة الإلزامية فإنه يهدف إلى ضمان الاستقرار في المعاملات بين أفراد المجتمع. هذا ويستمد العقد قوته من مبدأ (العقد شريعة المتعاقدين) ويقتضي ذلك أن ينشأ العقد صحيحاً ويلزم الأطراف بتنفيذ كل مل اشتمل عليه من التزامات طبقاً لما يوجبه مبدأ حسن النية، من الالتزام بالنزاهة والالتزام بالتعاون، فالأول يقتضي منع المتعاقد من كل غش أو تدليس يجعل تنفيذ الالتزام صعباً أو مستحيلاً، أما الثاني فيقتضي إفصاح المتعاقد للطرف الآخر وإطلاعه بكل الأحداث والمستجدات التي تتعلق بالتنفيذ العقد وعليه، فمبدأ القوة الملزمة للعقد يهدف إلى تكريس احترام العقد وقداسته وتنفيذه.

إلا أنه قد تعترض تنفيذ العقد صعوبة مزدوجة تفرض إعادة النظر في مبدأ القوة الملزمة للعقد وتتجلى هذه الصعوبة في حدوث ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية كما يتوقعها الأطراف أثناء إبرام العقد والتي تؤدي إلى الاختلال في التوازن الاقتصادي له وفي احترام إرادة الأطراف والتي هي جوهر العقد وتكريس لمبدأ (العقد شريعة المتعاقدين) وبالتالي رفض المساس بالقوة الملزمة للعقد أو رفض التعديل الاقتصادي للعقد.

فلا يجوز للأطراف الاتفاق على تعديل العقد لما فيه من مساس بمبدأ القوة الملزمة للعقد ورفض تدخل المشرع للتعديل كما فيه من المبدأ سلطان الإرادة ورفض منح القضاة سلطة التعديل.

أمام هذه الصعوبة والتطور الحاصل في المبادئ القانونية، لاسيما عدم أخذ مبدأ (العقد شريعة المتعاقدين) على إطلاقه مما دفع بالأطراف والمشرع والقاضي إلى البحث عن وسيلة لإعادة تنظيم العقد وضمان التوازن الاقتصادي له.

وتتمثل هذه الوسيلة في التعديل كمفهوم قانوني، يراد به إجراء قانوني يتم بمقتضاه تغيير عنصر أو عدة عناصر من العقد، سواء بتدخل المشرع أو باتفاق الأطراف أو القاضي وذلك بالإنقاص أو بالإضافة بغية المحافظة على العقد.

لقد أقر المشرع الجزائري التعديل في أحكام المادة 106 من التقنين المدني وتجد التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتھا المجتمعات في العصور الحديثة أدت إلى تقييد إرادة الأطراف لأن قداسية العقد لم تعد مطلقة بل تم تقييدها وذلك حفاظا على موازنة مصالح الأطراف حتى لا يطغى الطرف القوي على الطرف الضعيف وذلك بتدخل المشرع، لمعالجة التفاوت في المراكز الاقتصادية والاجتماعية وحماية المحكمة العليا للدولة، كأن يتدخل المشرع بتقنين بعض المجالات كحماية فئة المستهلكين، وذلك بوضع حد أقصى لأسعار بعض السلع ووضع حد أقصى لأجرة الأماكن.

هذه النصوص تشكل مساس بالحرية التعاقدية لأنها تهدف إلى حماية المتعاقد الضعيف من المتعاقد القوي باسم الناظم العام الحمائي.

كما يمكن للأطراف التدخل لحماية مصالحهم المشتركة من عملية التعديل أثناء إبرام العقد وذلك بالاتفاق المسبق على إدراج بعض البنود، كلما كان هناك إختلال في الالتزامات العقدية أو إدراج بنود لاحقة أثناء تنفيذ العقد لإعادة تنظيمه أو يجيز المشرع للقاضي تعديل العقد إذا اختل التوازن الاقتصادي به بسبب الاستغلال والغش طبقا لأحكام المادة 90 من التقنين المدني الجزائري والشروط التعسفية طبقا لأحكام المادة 110 من التقنين المدني هذا أثناء تكوين العقد أو يكون بسبب ظهور ظرف طارئ عام غير متوقع يهدد المدين بخسارة فادحة وكذا تدخل القاضي لتخفيض الشرط الجزائي الوارد في العقد، إذا كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أثناء تنفيذه. فحيطة المشرع في مراقبة مضمون العقد تتجسد في منح القاضي سلطة التدخل في تعديل العقد عن طريق عدة نظريات كنظرية الظروف الطارئة والشرط الجزائي.

بناء على ذلك يقسم الموضوع (موضوع أو دراسة تعديل العقد إلى ثلاثة فصول.

- الفصل الأول خاص بتدخل الأطراف في تعديل العقد وندرس بهذا الصدد في (المبحث الأول) ومدى حرية التعديل الاتفاقي وتأثيره على مصير العقد (في المبحث الثاني).
- سنتناول في الفصل الثاني تدخل المشرع لتعديل العقد وندرس هذا الفصل خلال مبحثين.
- المبحث الأول: مبرر التعديل القانوني وصوره.
- المبحث الثاني: حماية الأطراف من تدخل المشرع والاستثناءات الواردة عليه.
- أما الفصل الثالث هو خاص بتدخل القاضي لتعديل العقد ودراسة هذا الفصل يكون في مبحثين:
- مبحث أول: حالات تدخل القاضي ومبرره.
- مبحث الثاني: مظاهر تعديل العقد والقيود الواردة على سلطة القاضي.

الفصل الأول: تعديل اتفاقى للعقد

قد تكون الظروف دافعا للجوء الأطراف إلى تعديل العقد مما قد يمس بعنصر أو عناصر منه قد تكون جوهرية أو ثانوية وللأطراف الحرية في تعديل العقد طالما أنه مبني على اتفاقهم، إلا أنها مقيدة بقيود تعتبر استثناء عن القاعدة العامة، مما يدفعنا إلى البحث عن مدى الحرية في ذلك وتأثيره على مصير العقد.

المبحث الأول: حرية التعديل والقيود الواردة عليها

يستمد الأطراف حق حرية التعديل من مبدأ سلطان الإرادة طبقا لأحكام المادة 106 من التقنين المدني. لكن قد يترتب إطلاق هذه الحرية تجاوزات مذلة بمصالح الأطراف بما يدفعنا إلى ضرورة تقييدها.

المطلب الأول: الأصل حرية الأطراف في تعديل العقد

أصلا للأطراف حرية بتعديل العقد

تتجسد حرية التعديل في احترام الأطراف لشروطه القانونية، باعتباره تصرفا قانونيا وذلك بأن تكون إرادة الأطراف جدية للقيام بالتعديل وأن يكون الدافع من التعديل هو تحقيق مصلحة مشروعة ومشتركة للأطراف.

ويقتض التعديل على الزيادة أو الإنقاص أو حذف بعض الشروط، كما أن التعديل يرد في شكل معين إذا كان العقد الأصلي يشترط الشكلية بالنسبة للمسائل الجوهرية، أما إذا كان العقد الأصلي لا يشترط الشكلية في المسائل القانونية فإن التعديل إذا وقع عليها فإنه لا يشترطها أيضا.

حرية التعديل في حق متدول للأطراف لتمكينهم من القيام بالتعديلات التي يرونها مناسبة على مضمون العقد، سواء كانت مسائل جوهرية أو ثانوية لاسيما إذا لم تتحقق مصالح الأطراف من إبرام العقد الأصلي، فهنا نتجه إرادتهم رغم اختلاف وقوع الأسباب والظروف

إلى تعديل العقد. وكذا وضع حد لإخلال بالالتزامات التعاقدية وذلك باتفاق الأطراف على تغيير عنصر أو عدة عناصر في العقد الأصلي.

بما أن العقد شريعة المتعاقدين ما هو إلا نتيجة طبيعية لمبدأ سلطان الإرادة، فلا يجوز لأي من المتعاقدين أن ينفرد بتعديل العقد. لا تستطيع إرادة واحدة أن تغدر فيه وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في القرار صادر من الغرفة الاجتماعية بتاريخ 09 مارس 1999 غير منشور حيث قضت بأنه ليس للمستخدم الانفراد بتعديل شروط العقد إذا قضت بنقض الحكم شكلاً وبرفضه موضوعاً.

في قضية الحال كان العامل سائق تم تحويله إلى ورشة آخر كعامل يدوي بسيط، حيث رفض العامل ذلك.

حيث أنه ثابت فقها وقضاء أن التغيير في وظيفة العامل لا يتم إلا بناء على الإرادة المشتركة للطرفين – ومن تم قاضي الموضوع للمادة 63 من قانون 11/90 في محله¹، يكرس الأطراف حرية التعديل كلما اقتضت المصالح المشتركة ذلك.

الإرادة الحرة هي أساس تعديل العقود ولهذا يشترط في المتعاقد الذي يعبر عن إرادته في التعديل بأن تكون هذه الأخيرة صحيحة وخالية من عيوب الإرادة المنصوص عليها في القواعد العامة كالاستغلال والتدليس والإكراه كما أن حرية التعديل تمكن الأطراف من إعادة تنظيم العلاقة العقدية وذلك بترك كامل الحرية للأطراف في مراجعة العقد. مثلاً في حالة اعتراض تنفيذ العقد بسبب ظروف اقتصادية كإنهيار العملة أو ارتفاع الأسعار العامة يتدخل الأطراف لتعديل السعر التقديري بإدراج شروط تتضمن كيفية مراجعته وذلك بالاتفاق على اختيار أرقام مرجعة تتناسب وتغيرات تكاليف مواد البناء.

كما ليس من العدل أن يقوم البائع بمراجعة السعر التقديري بنفسه ويجب للمشتري اللجوء إلى أشخاص ذوي خبرة في الميدان لمراجعة السعر مع البائع.

يمكن تعديل شروط عقد العمل وطبيعته بناءاً على الإرادة المشتركة للعامل والمستخدم، مع مراعاة أحكام هذا القانون.¹

كما يكون الطرف الآخر الذي عرض عليه التعديل ملزما بالرد سواء بالقبول (في هذه الحالة يتم التعديل) أو بالرفض في هذه الحالة نكون أمام تعسف في استعمال حق أو سوء نية يترتب عنها إضرار بالغير مما يفرض تقييد حرية التعديل كما فيها من تجاوزات في استعمال حق حرية.

المطلب الثاني: القيود الواردة على حرية التعديل

توصلنا في السابق أن للأطراف الحرية في تعديل العقد بما تقتضيه المصلحة المشتركة للأطراف.

لكن من أجل حماية أحد من الأطراف الذي قد يلحقه ضرر من تقييد حرية التعديل وفقا لما تقتضيه قواعد الشكلية في بعض العقود أو مبادئ قانونية. فحرية التعديل ليست مطلقة بل مقيدة بالكتابة أو بعدم التعسف في استعمال الحق وحسن النية.

أولا: الكتابة

وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارا صادر في 07 نوفمبر 1994 بإلزامية وقوع التعديل في شكل معين إذا كان العقد الأصلي يتطلبه. إذ قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 07 نوفمبر 1994 والذي يؤيد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة حسين داي في 14 أبريل 1993 والقاضي يدفع مبلغ إضافي نظرا لتوسيع الأشغال المتفق عليها في العقد الأصلي، في حين كان الزاما على المتعاقد عند توسيع تلك الأشغال في وقت لاحق أن يدرجها كتابة حسب العقد الأصلي.

ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم قد خالفوا حكم القانون المنصوص عليه في المادة 561 من التقنين المدني الجزائري فالتعديل في هذه الحالة مقيد بالكتابة إذا كان العقد الأصلي من العقود الشكلية – كما أن حرية التعديل ليست مطلقة بل مقيدة بحسن النية، وبعدم التعسف في استعمال الحق.

ثانياً: التعسف في استعمال الحق

لكي يقيد التعسف في استعمال الحق إذا كان هناك طرف قد أحجم عن تعديل العقد (رفض للتعديل) رغم الإمكانية المتاحة أمامه لتعديله أو مقترح التعديل (المؤجر) بأن يقترح رفع الأجرة رغم عليه المسبق يتجاوز له للدخل الشهري للمستأجر. فيكون المؤجر (مقترح التعديل) في هذه الحالة متعسفا في استعمال حقه.

ونكون أمام التعسف في استعمال الحق إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 124 مكرر من التقنين المدني الجزائري التي تنص على ما يلي: "يعتبر استعمال حق تعسفياً في الأحوال التالية:

- إذا وقع بقصد الإضرار بالغير.
- إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير.
- إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة".

ولتطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق يكفي قصد الإضرار بالغير فقط أي أن تكون للمتعاقد قدرة عن التعديل أو متضرر له نية الإضرار بالمتقاعد معه.

من أجل حماية الطرف المتضرر من كل عمل يقوم به المتعاقد الآخر الذي من شأنه أن يؤثر في التعديل، يمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى العدالة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه على أساس المادة 124 مكرر من التقنين المدني الجزائري، كما أنه في عقد البيع على التصاميم لا يجوز للمتعاقد في الترقية العقارية أن يضع بند إلغاء أو تحديد المسؤولية أو الضمانات طبقاً لأحكام المادة 18 من القانون رقم 04-11 المؤرخ في 17 أبريل 2011 يحدد القواعد التي تظم نشاط الترقية العقارية (مادة 2) جريدة رسمية، العدد 14 لـ 06 مارس 2011 وذلك باعتبارها بنود تعسفية.

ثالثاً: حسن النية

القيد الثالث لحرية تعديل العقد هو حسن النية لأنه يفترض من التصرفات القانونية أن تتم بحسن النية طبقاً لأحكام المادة 1/107 من التقنين المدني الجزائري. ويقتضي حسن النية عند التعديل أن يكون الطرفان متعاونين وذلك بتقديم التسهيلات من أجل القيام بالتعديل.

المبحث الثاني: تأثير حرية التعديل على مصير العقد

إذا كان التعديل إجراء وقائي يحمي العقد من مخاطر الفسخ وعدم التنفيذ، فإن حرية الأطراف في تغيير عناصر العقد الأصلي سواء بالزيادة أو الإنقاص أو الهدف يترتب عليه تغيير في مضمون العقد، مما يدفعنا إلى التساؤل عن مصير العقد الأصلي: هل نكون أمام استمرار الرابطة العقدية الأصلية أو انقضائها وظهور عقد جديد؟

المطلب الأول: استمرار الرابطة العقدية الأصلية

رغم التغييرات التي قد ترد على عناصر العقد إلا أنها لا تؤثر في جوهر العقد ومن ثم استمراره وذلك في حالة بقاء الشروط الجوهرية للعقد وحالة بقاء الشروط الثانوية.

تعتبر العناصر الجوهرية شروطاً عامة مطلوبة لصحة العقد ولا يتم إبرام العقد بدونها. فإذا تم استبدال محل العقد الأصلي بمحل آخر جديد مماثل له دون التأثير على المحل الأصلي، فهذا الاستبدال المماثل هو الذي يحافظ على الرابطة القانونية وغالباً ما. بعد ذلك في حالة اللجوء إلى مناقشة ثمن الشيء المبيع. رغم أن الثمن يعد ركناً من أركان عقد البيع وهو المبلغ الذي يتعهد بمقتضى المشتري أن يدفعه للبائع مقابل الشيء المبيع. لا يشترط أن يكون ثمن الشيء المبيع معادلاً للقيمة الحقيقية أو التجارية.

وبالتالي نجد أنفسنا أمام نفس الثمن الذي تم الاتفاق عليه أثناء إبرام العقد الأصلي مما يؤدي إلى بقاءه.

لكن قد يحدث أن يقوم أحد الأطراف بتغيير مضمون العقد. فهل نكون في هذه الحالة أمام ظهور عقد جديد أو مجرد تعديل لطبيعته القانونية؟

المطلب الثاني: انقضاء العقد الأصلي وظهور عقد جديد

يترتب عن التغيير في عناصر العقد، أي استبدال محل العقد بمحل آخر ظهور فئة قانونية أخرى من العقود غير التي تم الاتفاق عليها من قبل الأطراف، مما يدعو إلى ظهور عقد جديد يختلف عن العقد الأصلي ويستطيع هذا الاختلاف البحث عن طبيعة العقد المعدل وخصائصه.

أولاً: حالة بسيطة اختلاف طبيعة المحل الجديد عن المحل الأصلي

يسعى التعديل من خلال استبدال بعض الشروط في العقد الأصلي بشروط أخرى إلى مواجهة الصعوبات التي قد تعترض الأطراف بغية تخفيف الهدف من العقد ومراعاة مصالح الأطراف والهم من هذا كله، هو المحافظة على استمرار واستقرار الرابطة العقدية. مفاد التغيير في طبيعة الالتزامات المتبدلة هو حلول شروط جديدة مختلفة عن الشروط السابقة تماماً في التشريع الجزائري.

التغيير في محل وسبب العقد يؤدي إلى التغيير في الطبيعة القانونية أي التغيير في التكيف القانوني للعقد من عقد إيجار إلى عقد قرض وذلك بإلغاء بدلات الإيجار مثلاً، فنكون أمام نشأة عقد جديد. في التشريع الجزائري، يشترط لقيام التجديد (la novation) طبقاً لأحكام المادتين 287 و 1/289 من التقنين المدني، وجود التزام قديم، نشوء التزام جديد ونية التجديد.

النظام القانوني للعقد المعدل يشمل العناصر المتفق عليها في العقد الأصلي إضافة إلى العناصر الجديدة التي تم إدخالها بموجب التعديل.

ثانياً: حالة التغيير الوارد على خصائص الشيء المستبدل

يتعلق الأمر بالأموال المثلثة أو الأموال المعينة بذاتها أو بنوعها وسواء كانت موجودة أو أشياء مستقبلية. فكل هذه الأموال تصاحبها مجموعة من الخصائص. حيث تنتقل الملكية في الأموال المنقولة بمجرد انعقاد العقد.

الأموال المثلثة والمنقولات المعينة بنوعية، فيتم نقل الملكية فيها بمجرد إفرازها وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 166 من قانون المدني ويراد بالإفراز تعيين قدر من الأشياء المتمثلة بذاتها وذلك عن طريق عمله عن سائر الأشياء التي تكون معه نوعاً واحداً. أما إذا كان المبيع عبارة عن شيء مستقبل لم يتم منعه فإن الملكية لا تنتقل بمجرد انعقاد عقد البيع لأن الشيء غير موجود لكن إذا تم منع المبيع أو تقدم منعه لدرجة تكفي لتعيينه، فإن ملكيته تنتقل إلى المشتري من هذا الوقت.

لكن في حالة ما إذا تم هلاك المبيع بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي قبل عملية الفرز، فتكون تبعة الهلاك على البائع طبقاً لأحكام المادة 369 من التقنين المدني (يفسخ عقد البيع). يكفي أثناء استبدال الأموال المثلثة أن يرد شيء مماثل فقط. لأن ما يهمنا هو بقاء العقد الأصلي.

أما المعينة بذاتها فبانعقاد العقد (وهي تمتاز بفرديتها ذاتها)، لا يمكن استبدالها بمال آخر أي نكون أمام التجديد إذا ما تعلق الأمر باستبدال منقول معين بذاته إلا أن هذه الفرضية ليست مطلقة. بل يمكن بإرادة الأطراف استبدال مال منقول معين بذاته بمال آخر مختلف عنه في الطبيعة هذا ما يبرر التعديل دون تغيير في الرابطة العقدية.

إذا يمكن القول أن النظام القانوني للعقد المعدل يخضع في الحقيقة لطبيعة الالتزامات المتبدلة وليس إلى خصائصه ونكون أمام مجرد تعديل العقد الأصلي إذا بقيت الشروط الجوهرية والثانوية للعقد دون تغيير وفي حالة تغيير الشروط الجوهرية أو اتفاق الأطراف على تغيير مضمون العقد، فإننا نكون مع عقد جديد.

الفصل الثاني: التعديل الشرعي للعقد

بالرجوع إلى أحكام المادة 106 من التقنين المدني، فإن التعديل تصرف قانوني يبيع اتفاق الأطراف استثناء على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين أما خارج هذا الاستثناء، فلا يمكن الافتداء به لأن مبدأ سلطان الإرادة يمنع بصفة مبدئية المشرع من تعديل العقود أثناء تنفيذها، كما أنه وبصفة مبدئية لا يجوز للمشرع أن يتدخل لتعديل العقود السارية التنفيذ وذلك احتراماً للقوة الملزمة للعقد من جهة، ورغبة المشرع في استقرار المعاملات العقدية من جهة أخرى.

إلا أنه نتيجة لتغيرات الاقتصادية واجتماعية لم يتوقعها الأطراف قد تؤدي إلى الإخلال بالتوازن العقدي، يلجأ المشرع إلى التدخل تلقائياً مستبعداً العقد شريعة المتعاقدين فتحل إرادته محل إرادة الأطراف وذلك لتكريس العدالة العقدية وحماية الفئة الضعيفة، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويتدخل المشرع الجزائي على أساس المادة 106 من التقنين، مما يدفعنا إلى البحث عن مدى التعديل القانوني وحدوده.

والإجابة على هذا السؤال، يجب التطرق إلى مبرر تدخل المشرع وصور التعديل القانوني وكذا حماية الأطراف من تدخل المشرع والاستثناءات التي ترد عليها.

المبحث الأول: مبرر التعديل القانوني وصوره

إن كثرة وتنوع القوانين الحديثة أدى إلى تدخلها بتأثيرها في حياة العقد، مما يفرض علينا البحث عن مبرر تدخل المشرع رغم خرقه لمبدأ سلطان الإرادة تقتضيه المصلحة العامة والمصالح المشتركة للأطراف وكذا البحث في المظاهر التي يتخذها المشرع في تعديل العقد، سواء بتعديل مدة العقد (فيما يخص عقد الإيجار، تجاري) أو قيمة الأداءات بغية استمرار العلاقة العقدية الأصلية.

المطلب الأول: مبرر تدخل المشرع

إذا كانت القاعدة العامة هي عدم جواز تدخل المشرع لتعديل أثار العقد التي تم الاتفاق عليها أثناء إبرامه والتي تشكل قانون الأطراف، فإن هذه القاعدة لا تؤخذ على إطلاقها لاسيما وأن الأطراف غالبا ما يجدون أنفسهم أمام تقلبات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية لم تأخذ في الحسبان. فهل هذه الاعتبارات وحدها كافية لتعديل المشرع العقد؟

وللإجابة عن هذا التساؤل يجب البحث في التدابير الاجتماعية التي تتخذ لحماية فئات خاصة من المجتمع في إطار المصلحة العامة وما يصدر عن تأثير المصلحة العامة على حماية المتعاقدين.

الفرع الأول: المصلحة العامة

المصلحة العامة صعب تعريفها لارتباطها بقواعد النظام العام والآداب العامة. الآراء تختلف على ذلك. حسب بعض الأستاذ فيلالي المصلحة العامة ما هي إلا تطبيق لقواعد النظام العام التي تسعى في الأساس إلى تثبيت نختلف المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتتغير المصلحة العامة بتغيير قواعد النظام العام التي تتسع وتضيق بحسب الأنظمة كما أنها تتغير بتغيير الزمان والمكان وتطور المجتمعات وفي كل الأوامر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

المصلحة العامة قوامها النظام العام ويقسم هذا الأخير إلى نظام العام توجيهي (ordre public économique de direction)، قول هذا الأخير إلى حق المنافسة والنظام العام الاجتماعي.

النظام العام التوجيهي أو الاقتصادي يسعلا إلى توجيه السياسة الاقتصادية والمالية للدولة وأهداف معينة لتحقيق السياسة العامة والتخطيط الاقتصادي بتحديد مثلا الأسعار منعا لتضخم أو لمحاربته.

تنظيم بمقتضاه النظام العام التوجيهي أو الاقتصادي تتدخل الدولة بتنظيم الاقتصاد عن طريق ضمان المنافسة الحرة، تشجيع السوق والدفاع عن المبادئ السياسية والمصالح العليا للدولة وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري من خلال قانون المنافسة، أمر 95-06 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالمنافسة الذي عدل في 15 أوت 2010 بموجب قانون رقم 05-10.

أما النظام العام الاجتماعي أو النظام العام الاقتصادي الحمائي هو نظام يسعى إلى حماية المصالح الخاصة لفئات معينة يرى المشرع جديرة بالرعاية وذلك لمعقنا اقتصاديا (كالعمال في عقد العمل).

وعليه مهما اختلف النظام العام سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا فإنه يكرس المصلحة العامة على حساب المصلحة العامة وذلك بالسماح للمشرع بالتدخل لتحديد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. وتتمثل فكرة المصلحة العامة المصلحة العليا للدولة وكذا حماية بعض الفئات الاجتماعية.

أولاً: المصالح العليا للدولة

وهي تلك المصالح التي تتعلق بسيادة الدولة سواء على المشتري الداخلي أو الخارجي. وتعتبر قواعد المصلحة العليا للبلاد قواعد أمرة لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها وإلا كانت لصرفتهم باطلة بطلانا مطلقا.

ويتجسد تدخل الدولة في التخطيط وتنظيم الأسعار العامة تماشيا مع تطور الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك بتضييق المصلحة العامة.

لكن هذه الأخيرة لم تقتص فقط على حماية مصالح العليا للدولة لأن هناك فئات خاصة في المجتمع حمايتها تعني بالضرورة تحقيق المصلحة العامة وهي ما تعرف بمصالح الفئات الخاصة.

ثانيا: مصالح الفئات الخاصة

إذا كانت القواعد العامة بموجب القانون المدني قد اقتصرّت على حماية المتعاقدين كمن شاب رضاه عيبا من عيوب الرضاء، أو كان قاصرا، فإن هذه الحماية أصبحت غير كافية مما أدى إلى تدخل الدولة في التقنية العقدية رغم أنها حكر على الأفراد وكذا الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق وتحرير التجارة الخارجية التي كانت حكرا للدولة، كل هذه الاعتبارات أدت إلى ظهور مجموعة من التشريعات لحماية هذه الفئات الخاصة. كل هذه التشريعات كانت نتيجة الضغوطات التي مرستها النقابات وكذا الجمعيات للدفاع عن مصالح هذه الفئات والفئة الضعيفة لها الحق في الحماية من قبل السلطات العامة بسبب ضعفها.

وتتجسد هذه المصالح بوضع الدولة لمجموعة من الواجبات لا يجوز للأطراف أن يجاوزها وإلا قد سيصبح ذلك التصرف القانوني باطلا وإن تدخل الدولة قد اقتضته عدة اعتبارات أهمها العدالة الاجتماعية أي حماية الطرف الضعيف اقتصاديا في مختلف العقود كالعامل في عقد العمل.

حيث عمل المشرع الجزائري على حماية فئة العمال، وذلك بموجب قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل المؤرخ في 21 أبريل 1990 وذلك بإدراج مجموعة من الحقوق والواجبات للعمال كالمدة القانونية للعمل، الراحة القانونية والعطل وكذا أهم التعديلات الواردة عليه بموجب أمر 96-21 المتعلق لعلاقات العمل المؤرخ في 09 جويلية 1996 كتمارس الحق النقابي وتسريح العامل (بموجب قانون رقم 91-29 لـ 21 ديسمبر 1991) وكذا تحديد الحد الأدنى للأجر إلى 18000 دج.

وفي حالة وجود شروط تعسفية في عقد العمل، المشرع تدخل لإلغائها وإدراج شروط أكثر مرونة مع مصالح العمال.

كما تدخل المشرع الجزائري في العشرية الأخيرة مجموعة من النصوص القانونية لحماية فئة المستهلكين بموجب قانون رقم 09-03 لـ 25 ففري 2009 يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وجعل ضمان البائع للمشتري ضمانا قانونيا من النظام العام. كما أن المشرع

الجزائري قد تدخل بتحديد أسعار في بعض عقود الخدمات المتعلقة بالأعمال الطبية والمنتجات الصيدلانية.

ويتم ضمان حماية هذه المصالح عن طريق قواعد النظام العام للحماية والتي غالبا ما تهدف إلى إعادة التوازن العقدي لفائدة الطرف الضعيف لأن حماية هذه المصالح هي الدافع لتدخل المشرع لتعديل العقد (قانون العمل قد عرف عدة التعديلات في 1991، 1996 و 1997 و 1999).

الفرع الثاني: دور المصلحة العامة في تعديل العقد

كما أثّرنا إليه سابقا يتدخل المشرع لتنظيم العقد بصفة أمرة يعني بوضع قواعد من النظام العام وذلك لإنقاص أو الزيادة في الالتزامات وحتى حذف البعض منها بحجة الوصول إلى حماية هذه المصالح، كما يتمتع للأطراف مناقشة الواجبات التي يضعها المشرع على عاتق الأطراف وذلك حفاظا على المصلحة العامة ومثال ذلك لا يجوز للأطراف في عقد العمل مناقشة العطل المدفوعة الأجر أو الراحة الأسبوعية كما يمنع في عقد العمل الاتفاق على أجر أقل من الحد الأدنى الذي ينص عليه القانون.

لكن يتدخل المشرع الجزائري لتعديل عقد العمل كلما اقتضت منفعة العمال ذلك وهذا ما نصت عليه المادة 62 من قانون 90-11 لـ 21 أفريل 1991 المتعلق بعلاقات العمل: "يعدل عقد العمل إذا كان القانون والتنظيم أو الاتفاقيات أو الاتفاقات الجامعية تملّي قواعد أكثر نفعا للعمال من تلك التي نص عليها عقد العمل".

وعليه فإن حماية الفئة الضعيفة أصبحت من منشغلات المصلحة العامة والتي يبررها ضعف هذه الفئة.

المطلب الثاني: صور التعديل القانوني

إن اقرار تدخل المشرع لم يأتي من أجل خرق مبدأ سلطان الإرادة وإنما أملت عدة مبررات، أهمها إعادة التوازن الإقتصادي للعقد ولأجل ذلك يتخذ المشرع عدة تدابير لتعديل العقد وغالبا ما يتجسد تدخله في صورتين:

الفرع الأول: فيما يخص عقد الإيجار التجاري

- (أ) في تعديل مدة العقد
(ب) في تعديل قيمة الأداءات أي الالتزامات

أولا: الامتداد القانوني للعقود الإيجار التجارية

من أجل تكريس استقرار المعاملات التجارية والمحافظة على دعمها، تدخل المشرع بتمديد عقود ذات الاستعمال التجاري. لقد حول المشرع الجزائري للمستأجرين في المواد 174/172 و 175 للقانون التجاري حق التمسك بالتجديد بشرط أن يكونوا قد استغلوا ذلك المتجر مدة سنتين متتابتين وفقا لإيجار واحد أو إيجارات متتالية شفاهية كانت أو كتابية وهذا طبقا لأحكام المادة 1/172 قانون تجاري. يبقى الامتداد القانوني مجرد تقنية يستخدمها المشرع لتعديل العقد وذلك من أجل تنظيم علاقات الفرد. وذلك من أجل تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم واستقرارها وحماية الطرف الضعيف في العقد.

ثانيا: إنقاص المدة

تدخل المشرع الجزائري بإنقاص مدة العمل في عقد العمل من 44 ساعة إلى 40 ساعة طبقا لأحكام المادة 02 للأمر 97-03 المؤرخ في 11 جانفي 1997 المتعلق بالمدة القانونية للعمل، ذلك من أجل السهر على حماية وصحة وسلامة العامل.

وعليه فإن تعديل مدة العقد مهما اختلفت الطرق التي يلجأ إليها المشرع سواء بتمديد العقد أو إنقاصه فإنها تسعى إلى تجسيد بقاء واستمرار العلاقة العقدية. لكن السؤال المطروح هو هل التعديل القانوني للعقد يقتصر فقط على مدة العقد أم يشمل أمور أخرى.

الفرع الثاني: تعديل قيمة الأداءات (أي قيمة الالتزامات)

يتدخل المشرع في هذه الحالة عن طريق تحديد الأداءات (الالتزامات) والتي يسعى من خلالها إلى إيجاد التوازن العقدي كلما كان إخلال اقتصادي بالعقد نتيجة لظروف خارجة عن إرادة الأطراف. فيتدخل بوضع حدودا قصوى للأسعار والأجور بقصد حماية الاقتصاد الوطني من جهة ومصالح الفئات الخاصة من جهة أخرى. ويستند المشرع في مختلف العقود على آليات منها الحد الأدنى للأجر المضمون في عقد العمل (يشكل ضمانا للعمال) وكذا الحد الأقصى بالنسبة الأجرة الإيجار).

تدخل المشرع لتعديل الحد الأدنى للأجور يكون بصفة دورية ومستمرة كلما اقتضت القدرة الشرائية للعمال ذلك. بنسبة الحد الأقصى فيما يخص الأجرة الإيجار، بالرجوع إلى أحكام المادة 193 من التقنين التجاري، فإن المشرع يشترط لمراجعة بدلات الإيجار ذات الاستعمال التجاري مدة ثلاث سنوات من تاريخ الشروع في الاستغلال أو تاريخ بدء الإيجار المجدد وعليه، المشرع يتدخل لتعديل العقد كلما اقتضت ذلك اعتبارات للمصالح العام عن طريق تشريعات حديثة وذلك لتفادي الإضطرابات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ظروف غير متوقعة.

يتخذ تدخل المشرع عدة صور، سواء تعلق الأمر بتعديل مدة العقد أو تعديل قيمة الأداءات، فكلها تسعى إلى إيجاد التوازن الاقتصادي للعقد وهذا ما يهدف إليه التعديل.

المبحث الثاني: حماية الأطراف من تدخل المشرع والاستثناءات الواردة عليه

المطلب الأول: حماية الأطراف من تدخل المشرع

إذا كان الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز للمشرع التدخل لتعديل العقد وذلك تجسيدا لمبدأ حماية الأطراف طبقا لمبادئ قانونية، مبدأ عدم رجعية القوانين من جهة ومبدأ استمرار القانون القديم من جهة أخرى.

الفرع الأول: مبدأ عدم رجعية القوانين

فليس من العدل أن يسري القانون الجديد بأثر رجعي وهذا ما كرسه التقنين المدني في المادة 02 فقرة 1 منه "لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له آخر رجعي". وعليه، فإن مبدأ عدم رجعية القوانين مبدأ قانوني يحترم إرادة الأطراف يعتبر ضمانا ويسعى مبدأ عدم رجعية القوانين إلى المحافظة على مصالح الأفراد ويكرس في نفس الوقت استقرار المعاملات. لكن لا يمكن لأحد أن ينازع فيها للمشرع حق للتدخل في تعديل العقد كلما اقتضت ظروف استثنائية.

يمكن القول بأن مبدأ عدم رجعية القوانين مطلق بالنسبة للقاضي طبقا لأحكام المادة 02/ فقرة 1 من التقنين المدني. في حالة تنازع القوانين من حيث الزمان، لا يجوز للقاضي اللجوء إلى تسوية النزاع عن طريق النص على رجعية القانون.

وجب على المشرع أن يراعي أثناء تدخله استقرار لأكثر حماية الأطراف يجب امتداد سريان القانون القديم.

الفرع الثاني: امتداد سريان القانون القديم

مبدأ استمرار القانون القديم هو المبدأ الذي تخضع بمقتضاه آثار العقود الجارية لسلطان القانون الذي تم إبرام العقد في ظله. مبدأ استمرار القانون القديم يهدف إلى حماية العقود من القوانين الجديدة التي تأتي لتعديل آثار العقود المترتبة في ظل القانون القديم ولا يجوز للقانون

الجديد أن يعدل أو يضيف أو ينقص من هذه الآثار القانون القديم يستتر في تنظيم العقود الجارية المبرمة في ظلّه. ذلك احتراماً إلى إرادة الأطراف ومن أجل المحافظة على التوازن في العقد.

لكن يمكن للمشرع التدخل غالباً بوضع قواعد قانونية لتنظيم عقد العمل سواء تعلقت بالحد الأدنى للأجر أو ساعات العمل ويهدف بذلك إلى حماية فئة العمال دون النظر إلى إرادة الأطراف.

يتدخل المشرع بصورة منظمة مراعيًا مراكز الأطراف وتصرفاتهم وتخفيف العدالة، وذلك باستخدام مبادئ قانونية تشكل استثناءات على حماية الأطراف من تدخل المشرع.

المطلب الثاني: التدخل الاستثنائي للمشرع

قد تعترض تنفيذ العقد صعوبات مردها إلى تقلبات اقتصادية واجتماعية يترتب عنها الإخلال بتوازنه الاقتصادي، الأمر الذي أدى في الوقت الحاضر إلى كثرة تدخل القوانين الحديثة في حياة العقد. ويتم هذا التدخل وفقاً لمبدأ الأجر الفوري والآخر الرجعي للنص الجديد المعدل للعقد.

الفرع الأول: مبدأ الأثر الفوري للقانون الجديد

مفاد مبدأ الأثر الفوري للقانون الجديد أن يسري القانون الجديد بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة أي كل ما يتكلف بآثارها المستقبلية على إعتبار أن الآثار الفوري هو الأفضل لما يحققه من تطور وتقدم بالنظر إلى القانون القديم.

تطبيق مبدأ الأثر الفوري في مجال العقود لا يمكن الأخذ به على الإطلاق ووقع هناك اختلاف فقهي حول إمكانية تطبيقه على العقود. فمنهم من يتمسك بالفرقة بين القواعد القانونية الآمرة المتخلقة بالنظام العام والقواعد القانونية المكملة ومنهم من يتمسك بالفرقة بين القوانين المتعلقة بالنظام القانوني والقوانين المتعلقة بالمراكز العقدية.

أولاً: الاتجاه الأول

يرى هذا الاتجاه أن القوانين المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة تسري بأثر مباشر على العقود الجارية وأن قوانين النظام العام تأتي لتعديل شروط العقد. القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يأتي لتعديل العقد في جميع مراحله.

ويتجسد التدخل الاستثنائي للمشرع في عدة عقود مثلاً في عقد العمل يتدخل المشرع بقوانين أمرة متعلقة بالنظام العام تسري بأثر فوري وذلك بإنقاص ساعات العمل أو وضع حد أدنى للأجر المضمون في عقود العمل.

وكذا المر بالنسبة للعقود المتعلقة بالاستهلاك أصبح الضمان (الذي كان سابقاً يخضع إلى أحكام التقنين المدني) قاعدة أمرة متعلقة بالنظام العام لا يجوز للأطراف مخالفتها طبقاً لأحكام المواد 13 إلى 16 للقانون رقم 09-03 لـ 25 فيفري 2009 يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.

يؤكد أنصار هذا الإتجاه على أن للمشرع الحرية الكاملة في تعديل العقد بقوانين جديدة من النظام العام بما تقتضيه المصلحة العامة.

ثانياً: الاتجاه الثاني

يتزعم هذا الاتجاه الفقيه الفرنسي روبيي (Roubier) الذي يرفض الرأي الأول مؤكداً بأن التشريعات المتعلقة بنظام العقود لا يكون لها أثر على العقود الجارية حتى ولو كانت تشريعات أمرة تتخلف بالنظام العام وذلك على أساس أن العقد هو الوسيلة التي أعطاه القانون للأفراد لتخفيف مراكزهم القانونية الخاصة على الوجه الذي يرونه.

لكن في هذا الموضوع يجب التفرقة في مجال العقود بين القوانين المتعلقة بالنظام القانوني (المراكز القانونية والقوانين المتعلقة بالمراكز العقدية).

فالأولى، المشرع يتكفل بتنظيمها وترتب أثارها كما هو الشأن في عقد الزواج وعقد العمل والقوانين المتعلقة بالملكية ففي هذه الحالة تسري القوانين الجديدة بآثار فوري على العقود الجارية.

أما المراكز العقدية، فيراد بها تلك العلاقات التي يكون للأفراد كامل الحرية في تنظيمها وترتيب أثارها كعقد البيع، ففي هذه الحالة يستمر القانون الذي تم إبرام العقد في تطله عن السريان وذلك حفاظا على استقرار المعاملات بين الأفراد مما يؤدي إلى رفض الآثار الفوري على المراكز العقدية.

لكن من الناحية العملية هذا الاتجاه لا يمكن الأخذ به على الإطلاق لأن غالبا ما يصعب التفريق بين المراكز القانونية والمراكز العقدية وبالتالي يختلط النظام القانوني والمراكز العقدية. يتدخل المشرع في بعض العقود ولسبيل المثال عقد العمل بصفة دورية بتعديل بعض الشروط في عقد العمل. (مثلا إنقاص ساعات العمل إذا اقتضت صفة وسلامة العامل ذلك أو ارتفاع الحد الأدنى للأجر المضمون. كما يجوز للمشرع التدخل في العقود بالنص صراحة على سريان القانون الجديد بآثار رجعي.

الفرع الثاني: الآثار الرجعي للنص الجديد لتعديل العقد

مبدأ عدم رجعية القوانين يقيد بطبيعة الحال القاضي وليس إرادة المشرع في التدخل لتعديل العقود وذلك بالنص صراحة على سريان القانون الجديد بآثار رجعي على العقود القائمة في ظل قانون معين ذلك تحقيقا للمصلحة العامة. يقتصر تدخله على الضرورة القصوى التي تقتضيها اعتبارات اجتماعية وسياسية واقتصادية من أجل تحقيق العدل.

في الحقيقة تدخل المشرع لتعديل العقد يأتي لتقدير بند غير مكتوب بآثار رجعي. يلجأ المشرع إلى إعادة كتابة شروط غير مكتوبة وإدراجها في العقد وذلك بالنص على رجعيته صراحة فيما يتعلق بآثارها بمقتضى القانون الجديد. (القانون الجديد ينص صراحة على رجعية هذه الشروط التي يمكن القول أن تدخل المشرع لتعديل العقد ما هو في الحقيقة إلا استثناء على مبدأ سلطان الإرادة أملت المصلحة العامة.

وهذا ما كرسته المحكمة العليا في قرارها الصادر في 30 مارس 1983، مجلة قضائية 1983 العدد 2، ص. 42 بمناسبة قرار إلغاء تأمين أرض مشاعة الصادر في 03 ماي 1977.

حيث اعتبرت المحكمة العليا أن قرار إلغاء تأمين أرض مشاعة صادر في 03 ماي 1977 يكون له أثر رجعي مؤداه إبطال كل التصرفات الواردة على الأرض المؤممة أثناء فترة التأمين ويترتب عنه رجوع الأطراف إلى حالة الشيوع التي كانوا عليها من قبل.

الفصل الثالث: التعديل القضائي للعقد

تقتصر وظيفة القاضي في الأصل على تفسير العقود وتطبيقها. لكن قد تحدث ظروف تؤدي إلى إلحاق خسارة فادحة بأحد المتعاقدين أو ضرر فاحش بهما. هذه الحالة دفعت المشرع الجزائري إلى الترخيص للقاضي بتعديل العقد وذلك استثناء للمبدأ القاضي بأن العقد شريعة المتعاقدين.

إذا السؤال المطروح هو: ما هي الحالات التي يجوز فيها للقاضي تعديل العقد، ما هو مبرره وما هي وسائل تعديل العقد والقيود الواردة عليه:

المبحث الأول: حالات تدخل القاضي ومبرره

منح المشرع الجزائري للقاضي سلطة التعديل للعقد وفي حالتين نظرية الظروف الطارئة والشرط الجزائي.

المطلب الأول: حالات تدخل القاضي لتعديل العقد

الفرع الأول: نظرية الظروف الطارئة

مفاد نظرية الظروف الطارئة أنه أثناء تنفيذ العقد يتبين للأطراف حادث غير متوقع، يؤدي إلى اختلال التوازن الاقتصادي مما يلحق بالمدين خسارة فادحة ويصبح تنفيذ الالتزام مرهقا بالنسبة للمدين.

هذه النظرية حديثة ومع ذلك فالقانون المدني الفرنسي لم يأخذ بها المشرع الجزائري تبناها في الفقرة الثالثة من المادة 107 من التقنين المدني.

نجد تطبيقات هذه النظرية في عدة عقود منها عقد المقاوله طبقا للمادة 3/561 من التقنين المدني الجزائري.

يتمثل تعديل العقد في رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. لكن حتى يتمكن القاضي من تطبيق نظرية الظروف الطارئة طبقاً لأحكام المادة 3/107 من التقنين المدني الجزائري يجب توفر مجموعة من الشروط المحددة أهمها:

أولاً: أن يكون العقد المراد تعديله متراخي التنفيذ

مفاد العقد المتراخي التنفيذ، أن تكون هناك مدة زمنية من تاريخ انعقاد العقد إلى تاريخ نفاذه. وغالباً ما نجده في العقود الزمنية (تنفيذها يمر على مراحل متتالية عبر الزمن) كعقد الإيجار كما للقاضي سلطة في تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود الفورية، لكن قد يتم تأجيل تنفيذها إلى أجل متتالية ذلك بموجب اتفاق الأطراف على تأجيله كالبيع بالتقسيط.

ثانياً: أن يطرأ حادث استثنائي عام غير متوقع أثناء مرحلة التنفيذ

يشترط المشرع في الحادث الطارئ، أن يكون استثنائياً، عاماً وغير متوقع هو حادث نادر غير مألوف وكالفيضانات والزلازل والحروب.

لذا الطرف الطارئ يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً. مثلاً إصابة الحول بالدودة حادث مألوف ولكن قد يبلغ من الجسامة حداً غير مألوف.

كما يجب أن يكون الحادث الاستثنائي عاماً يعني أن لا يكون الحادث الاستثنائي خاصاً بالمدين وحده بلا يجب أن يشمل فئة من الناس.

كما يجب أن يكون الحادث الاستثنائي غير متوقع الحمول وفي نفس الوقت لا يستطيع المدين تفاديه أو دفعه عن نفسه.

يجب أيضاً أن يؤدي هذا الحادث الاستثنائي إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً. الحادث الاستثنائي يهدد المدين بخسارة فادحة مما يؤدي إلى إرهاب في تنفيذ التزامه دون استحالة التنفيذ. لم يحدد المشرع الجزائري مقدار الإرهاب في المادة 3/107 من التقنين المدني بل أكلف فقط بأن تكون الخسارة فادحة. المشرع حول للقاضي سلطة لتعديل العقد أثناء التنفيذ بسبب الاختلال في التوازن العقدي. وبالتالي للقاضي سلطة تقديرية واسعة لتقديره حسب الظروف المحيطة بالعقد.

الفرع الثاني: الشرط الجزائي

يراد به الاتفاق مقدما بين الدائن والمدين على مقدار التقويم الذي يستحقه الدائن في حالة عدم تنفيذ المدين التزامه أو تأخره في تنفيذه. هذا الشرط فهو مدرج في العقد الأصلي أو تم الاتفاق عليه لاحقا.

وقد نظم المشرع الجزائري أحكام الشرط الجزائي في المواد 183، 184 و185 من التقنين المدني.

ويشترط لاستحقاق الدائن مقدار التعويض المتفق عليه مجموعة من الشروط أهمها الخطأ، الضرر، العلاقة السببية وإعذار المدين.

أولاً: الخطأ للمدين

في حالة امتناعه عن تنفيذ التزامه العقد أو تأخره ويعتبر الخطأ أساس الشرط الجزائي. (شرط أساسي لاستحقاق التعويض).

ثانياً: الضرر

يعتبر الضرر أساس تقدير التعويض الواجب أدائه في حالة اختلال المدين بإلزامه سواء بسبب عدم التنفيذ أو التأخير في تنفيذه. ويترتب عن انتفاء الضرر عدم استحقاق الشرط الجزائي وهذا ما نصت عليه المادة 1/184 من التقنين المدني الجزائري. الشرط الجزائي من النظام العام. (مادة 3/184 من التقنين المدني الجزائري).

ثالثاً: العلاقة السببية بين الخطأ والضرر

يجب وجود علاقة سببية بين خطأ المدين يعني امتناعه عن تنفيذ التزامه العقدي أو تأخره في تنفيذه والضرر لاحق بالدائن. يمكن للمدين قطع العلاقة السببية بإثبات السبب الأجنبي أو خطأ من الدائن.

رابعاً: الإعذار

المشرع الجزائري يشترط الإعذار لاستحقاق الشرط الجزائي، إضافة إلى الخطأ، الضرر والعلاقة السببية طبقاً لأحكام المادة 179 من التقنين المدني. لكن يعفى الدائن من إعذار المدين في بعض حالات المنصوص عليها في المادة 181 من التقنين المدني. بعد فحص كل شرط على حدة يتدخل القاضي لتعديل الشرط الجزائي.

المطلب الثاني: مبرر تدخل القاضي

الهدف من التعديل هو إعادة التوازن الاقتصادي للعقد. لهذا الغرض العدالة تقتضي أن يتدخل القاضي لإعادة التوازن الاقتصادي للعقد.

الفرع الأول: العدالة

اختلال التوازن الاقتصادي للعقد الذي قد يقع بسبب ظروف اقتصادية، اجتماعية وسياسية يلزم القاضي أن يتدخل لتعديل العقد على أساس العدالة.

العدالة ما هي إلا رفع الظلم عن أحد المتعاقدين بما يحقق له المساواة في الالتزامات المتقابلة. لكن ما هو تأثير العدالة في تدخل القاضي لتعديل العقد؟

الفرع الثاني: تأثير العدالة في تدخل القاضي

العدالة نجد مصدرها في أحكام المادة 2/01 من التقنين المدني. العدالة تسعى إلى تحقيق فائدة عملية لأنها ذات طبيعة عامة والعقد ما هو إلا وسيلة لتحقيق العدالة فليس من العدل إبطاله أو فسخه بل الحفاظ على العقد. لذلك وجب على المشرع وبهدف تحقيق العدالة أن يمنح للقاضي سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياته إعادة توازن الالتزامات المحلة ويكون من القاضي للتعديل غالباً العدالة العقدية بما تفرضه من إعادة التوازن في الالتزامات المتقابلة للمتعاقدين.

المبحث الثاني: وسائل تعديل العقد والقيود الواردة على سلطة القاضي

حول المشرع الجزائري سلطة تعديل العقد بمجرد الشروط القانونية المنصوص عليها في المواد 3/107، 184 و 185 من التقنين المدني ولذلك القاضي يستحمل بعض الوسائل (مطلب أول) لكن سلطة القاضي في التعديل لا تؤكد على الإطلاق بل وجب تقييدها (مطلب ثاني).

المطلب الأول: وسائل تعديل العقد

يلجأ القاضي إلى عدة وسائل لتعديل العقد وذلك في حالة رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول أو في حالة تعديل الشرط الجزائي.

الفرع الأول: رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول

طبقاً لأحكام المادة 3/167 من التقنين المدني، فإن المشرع لم يحدد للقاضي طريقة لرد الالتزام المرهق وإنما ترك له الحرية في اختيار طريقة مناسبة للحد من الأرهاق وتتمثل هذه المظاهر فيما يلي:

- إنقاص الالتزام المرهق يعني بالمفهوم الفرنسي Réduire
- زيادة قدر الالتزام المقابل – يقوم القاضي في حالة ارتفاع فاحش للأسعار بزيادة في التزامات الدائن بهدف الوصول إلى التوازن بين مصلحة الطرفين (مادة 561 ق.م).
- وقف تنفيذ العقد لفترة محددة أو غير محددة من الوقت حتى يزول آثار الطرف الطارئ. (مثلاً في حالة ارتفاع أسعار مواد البناء وكان المقاول تعهد بإقامة مبني في هذه الحالة القاضي يوقف تنفيذ العقد حتى يزول أثر هذا الطرف).

الفرع الثاني: تعديل الشرط الجزائي

يتدخل القاضي لتعديل مضمون الشرط الجزائي عن طريق التخفيض سواء كان الشرط الجزائي مفرطاً (مبالغاً فيه) أو إذا قام المدين بالتنفيذ الجزئي لالتزامه طبقاً لأحكام المادة 2/184 من القانون المدني واستثناءً، فإن المشرع منح للقاضي سلطة التعديل عن طريق الزيادة في التعويض المتفق عليه إذا ثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً طبقاً للمادة 185 من قانون مدني.

المطلب الثاني: القيود الواردة على سلطة القاضي

إذا كان المشرع الجزائري حول للقاضي سلطة التدخل لتعديل العقد سواء بسبب الظروف الطارئة أو الشرط الجزائي، فإن هذه السلطة ليست مطلقة بل مقيدة بمجموعة من الضوابط تضمن عدم تعسفه في استعمال سلطته قد تكون سلطة القاضي في تعديل العقد مقيدة بمناسبة نظرية الظروف الطارئة (فرع أول) أو بمناسبة الشرط الجزائي (فرع ثاني).

الفرع الأول: القيود الواردة على سلطة القاضي بمناسبة نظرية الظروف الطارئة

يتجسد تدخل القاضي في تعديل العقد بسبب الظروف الطارئة برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول – سلطة القاضي مقيدة ببعض الضوابط القانونية وأهمها: مراعاته للظروف المحيطة بالقضية، الموازنة بين مصلحة المتعاقدين ورد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.

أولاً: مراعاة القاضي الظروف المحيطة بالقضية

طبقاً للمادة 3/107 من القانون المدني "أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف ... " ومنه يجوز للقاضي أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول تبعا للظروف وعبرة "تبعا للظروف تعتبر كقيد لسلطة القاضي".

ثانيا: الموازنة بين مصلحة المتعاقدين

يقتصر هذا القيد على توزيع عبء الظرف الطارئ بين المتعاقدين، أي لا يمكن للقاضي أن يرفع الإرهاق كليته عن الكدين ويضعه على عاتق الدائن لأن نظرية الظروف الطارئة لا تهدف إلى رفع الإرهاق كليا.

ولهذا وجب على القاضي أثناء قيامه بتوزيع عبء الظرف الطارئ بين المتعاقدين من توخي الدقة بهدف تحقيق العدالة العقدية وهذا ما تضمنته المادة 107 من التقنين المدني: ... جاز للقاضي ... وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين. وجي على القاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول أن يراعي مصلحة الطرفين.

ثالثا: رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول

رد الالتزام المرهق يكون إما بإنقاص في الالتزامات التعاقدية أو زيادة في الالتزامات المقابلة أو وقف تنفيذ العقد. المشرع الجزائري حول للقاضي سلطة التعديل دون سلطة فسخ العقود.

الفرع الثاني: القيود الواردة على سلطة القاضي بمناسبة الشرط الجزائي

إن إقرار المشرع للقاضي سلطة تعديل الشرط الجزائي ووجد لحماية الطرف الضعيف إلا أن سلطة ليست مطلقة، بل مقيدة لأن إطلاقها يؤدي بالضرورة إلى ظلم الطرف الضعيف. يجب أن يكون دور القاضي كأمين على العدالة. لهذا تدخله يكون مقيدا في جميع مظاهر سلطته.

(1) فلا يجوز للقاضي ممارسة سلطته في التعديل إلا إذا بلغ الشرط الجزائي درجة كبيرة من الارتفاع أو الانخفاض، مما يؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالطرف الضعيف مادة 184 (2) للقاضي حرية كاملة في تخفيض الشرط الجزائي. لكن فهو ملزم بتسبب حكمه سواء تعلق الأمر بالإفراط أو التنفيذ الجزائي أو حتى زيادة مقدار التعويض. هذه المسائل القانونية تخضع لرقابة المحكمة العليا وإن قضاة الموضوع ملزمون بتسبب أحكامهم في حالة قبولهم التعديل وذلك بتبيان المبلغ المتفق عليه كان مبالغا عنه.

(2) كما يتقيد القاضي بمبلغ الشرط الجزائي في حالة التنفيذ الجزائي للالتزام الأصلي. فيقوم القاضي بالتنفيذ إلى الحد المناسب مراعيًا مصلحة المدين والدائن. القاضي مقيد بالوصول إلى حد يتناسب فيه الضرر مع قيمة الشرط الجزائي دون تحقيق المساواة. كما يتقيد القاضي بحسن النية الذي يفترضه لأن تنفيذ العقد طبقًا لأحكام المادة 107 من قانون مدني واجب التنفيذ وفقًا لمضمونه وبحسن نية. أي أن المدين ملزم بتنفيذ التزامه الأصلي في حالة زيادة مقدار التعويض بسبب غش المدين أو خطئه فسوء النية هنا واجب الإثبات من طرف الدائن في هذه الحالة جاز للقاضي زيادة مقدار التعويض حتى يتساوى مع الضرر اللاحق بالدائن.

(3) كما يتقيد القاضي في ممارسة سلطته على طلب أحد المتعاقدين الذي يكون قد تضرر من عدم التناسب بين الضرر اللاحق به ومقدار التعويض لأن القاضي مقيد بمبدأ "لا يحكم القاضي إلا بما يطلبه الخصوم" وإلا كان متعسفًا في استعمال سلطته. المشرع لم يمنح للقاضي معايير ولا عناصر التقدير والتخفيض عمومًا للقاضي سلطة التدخل لتعديل العقد لحماية الطرف الضعيف وكذا تحقيق المساواة والعدالة بين الأطراف سواء نتيجة الإرهاق أو الافتراض في الشرط الجزائي.